

0012622-46.2017.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0012622-46.2017.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012622-46.2017.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 363/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, 338/2017 - Delegacia de Polícia de Rio Claro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Graziele Isaque de Macedo Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

GRAZIELE ISAQUE DE MACEDO SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, assim porque, no 14 de dezembro de 2017, por volta das 16h08min, na Avenida 27, com a Rua 17, Bairro do Estádio, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, vendeu 02 (dois) "eppendorfs" da substância entorpecente que determina dependência física e psíquica denominada cocaína, trazia consigo 01 (um) "eppendorf" da mesma substância entorpecente, e ainda guardava e tinha em depósito outros 29 (vinte e nove) "eppendorfs" da mesma substância, totalizando com aqueles outros peso líquido aproximado de 5,03 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação preliminar de fls. 16, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 79/80).

Regularmente notificada (fls. 122), seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor da acusada (fls. 125/126), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 08 de março de 2019 (fls. 136/137).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa, interrogando-se em seguida a acusada (fls. 156/157, 200).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da primariedade, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação de regime prisional inicial aberto, em caso de reconversão, com a restituição da quantia de R\$ 244,00 apreendida em poder da acusada por não ter ficado suficientemente demonstrado que decorria da atividade ilícita (fls. 200).

Já ilustre Defensora Pública, sustentando insuficiente a prova produzida, requereu a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Reclamou, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância, diante da quantidade irrisória de entorpecente apreendido, a ensejar a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, ou para aquele previsto no artigo 33, § 3º do mesmo Diploma Legal. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu seja fixada a pena-base no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e imposição de regime prisional inicial aberto, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Requereu, por fim, a restituição da quantia em dinheiro apreendida em poder da acusada e da testemunha (fls. 200).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se à acusada a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, assim porque vendeu, trazia consigo e guardava, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão de fls. 15, laudo de constatação preliminar de fls. 17 e laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 90/92, com resultado positivo para cocaína.

E não se mostra possível a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, em razão do maior potencial lesivo da substância (cocaína) e, ainda, porque se cuida de crime de perigo abstrato, não obstando a tipificação do delito a menor quantidade de entorpecente apreendida.

Sobre isto: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.163/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)" Grifos nossos.

Controverte-se sobre a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Reiterando em juízo o que exposto inicialmente, a acusada afirmou que na ocasião foi efetivamente apreendida uma porção de cocaína em seu poder e duas com o seu acompanhante, negando que outras porções da mesma substância tenham sido apreendidas nas proximidades do local onde se encontravam, não tendo conhecimento da origem daquelas exibidas na Delegacia de Polícia, acondicionadas em envelopamentos

de cor diversa (rosa). Acrescentou que a quantia em dinheiro que levava consigo pertencia a seu genitor. Por fim, negou tivesse entregado algo para Alex, quando abordados, ou recebido dele alguma quantia em dinheiro (fls. 200).
Todavia, a versão deduzida pela acusada foi contrariada pela prova produzida. Os Policiais Militares, Wellington e Marcus Vinicius, que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, afirmaram que estavam em patrulhamento, em local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecente, quando avistaram GRAZIELE entregando algo para Alex, momento em que este repassou quantia em dinheiro para ela. Em razão da movimentação, foi realizada abordagem. A transação ocorria em uma esquina, sendo que a acusada e a testemunha não visualizaram que a viatura tinha se aproximado, sendo possível acompanhar toda a movimentação. Em poder de GRAZIELE foi apreendida a quantia de R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) e um eppendorf contendo cocaína, já com Alex foi localizada a quantia de R\$ 19,00 (dezenove reais), além de dois invólucros idênticos àqueles anteriormente apreendidos com a acusada.

Além disto, ainda segundo o exposto, a aproximadamente cinco metros de onde abordados, foi encontrada outra quantidade da mesma substância entorpecente, contendo as mesmas características e embaladas da mesma forma, aduzindo os Policiais que não era a primeira vez que a acusada era abordada naquele local, embora tenha ela negado a prática delitiva, informando que o dinheiro provinha de serviço que havia realizado capinando calçadas -- versão que contradiz aquilo que exposto em Juízo sobre a origem do dinheiro (fls. 156/157).

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, considerando que a acusada se encontrava em conhecido local de ponto do tráfico ilícito, portando entorpecente, em movimentação típica da mercancia, possível a conclusão de que a cocaína apreendida em poder dela realmente estava destinada ao comércio ilícito, não obstante eventual condição de usuária.

De outra parte, e isto foi reconhecido pelo Ministério Público, há dúvida sobre se a acusada na ocasião estava de fato dedicada efetivamente à disseminação do entorpecente, possibilitando, portanto, o reconhecimento da figura privilegiada, diante da possibilidade da incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a

quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Por fim, a pena-base cominada deve ser reduzida, em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

A acusada era primária, não ostentando, a época dos fatos, condenação criminal anterior, não havendo indicação suficiente de que estivesse já dedicada à atividade criminosa, de tal modo que, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica da acusada.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo.

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda.

Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes.

No entanto, a fim de observa os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo

Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO a acusada GRAZIELE ISAQUE DE MACEDO SILVA à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo, deixando-se de operar o perdimento da quantia apreendida, em razão de não ter se evidenciado ser decorrente da ação ilícita, com oportuna restituição.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA